

1501594-32.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que é usuário de maconha desde a adolescência. Aduziu que possui registros por atos infracionais análogos a tráfico e furto perante a Vara da Infância e Juventude. Afirmou que as drogas estavam escondidas a menos de um metro de distância de onde estava. Disse que o responsável pela "biqueira" sempre está naquele local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501594-32.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501594-32.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Keven Robert Silva de Andrade

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Keven Robert Silva de Andrade foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque por volta das 18 horas de 16 de novembro de 2021, na praça poliesportiva situada na Rua Antônio Marcondes da Silva, próximo ao nº 250, Parque Aeroporto, Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e tinha em depósito para fins de venda a terceiros consumidores, 71 invólucros de maconha, com massa líquida de 76,19 gramas, 29 pinos de cocaína, com massa líquida de 7,68 gramas, e 9 pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida de 1,5 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica.

Segundo apurado pela acusação, pouco após deixar o sistema prisional, o réu voltou a exercer o malsinado e vil comércio de narcotráfico visando obter renda de forma rápida e fácil.

Na tarde dos fatos, o acusado se deslocou à praça situada no endereço supramencionado, local conhecido como ponto de venda de drogas, levando consigo uma

sacola contendo diversos e variados entorpecentes, onde permaneceu aguardando interessados na aquisição. Visando a não levantar suspeita, ele escondeu as sacolas próximo ao alambrado.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram-no conversando com outros indivíduos, de modo que, em razão da suspeita levantada, procederam às abordagens, não sendo encontrado nada de ilícito na posse deles. Todavia, durante o procedimento de revista, os policiais encontraram a sacola escondida próximo ao alambrado, localizando em seu interior 71 invólucros de maconha, 29 pinos de cocaína e 9 pedras de crack, drogas que estavam embaladas e prontas para serem vendidas.

Indagado a respeito, o réu prontamente assumiu a propriedade das drogas, admitindo que estava comercializando naquela localidade, razão pela qual ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida às fls. 63/65.

Citado (fls. 85), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 94).

Em audiência foram ouvidas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, alegando que a autoria e a materialidade foram comprovadas. Enfatizou que o réu havia sido posto em liberdade pouco tempo antes de ser flagrado no tráfico de drogas, reiterando a mesma conduta pela qual estava segregado. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Destacou que o réu ostenta maus antecedentes. Defendeu a imposição de regime inicial fechado. Rechaçou a possibilidade de aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, especialmente pelos maus antecedentes.

A Defesa aduziu que o réu estava consumindo maconha na companhia de outras pessoas, mas nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Destacou que o acusado é usuário de drogas e conhecia o responsável pela venda de drogas no local, inclusive identificando-o em juízo. Enfatizou a narrativa fornecida em autodefesa. Rogou pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Pugnou pela concessão de liberdade.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de tráfico de drogas, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão embasadas em auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5), termo de depoimento (fls. 6/7), termo de interrogatório (fls. 8), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 15/19), auto de qualificação e vida pregressa (fls. 22), laudo pericial (fls. 87/90) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha Fábio Nogueira Silva informou que estava em patrulhamento pela região. Relatou que avistou alguns indivíduos em uma quadra de esportes. Enfatizou que a atitude das pessoas ensejou a abordagem, mas nada de ilícito foi localizado. Em revista pelo local, seu colega de farda encontrou uma sacola contendo diversas drogas. Questionado sobre as drogas, o réu admitiu a propriedade dos objetos e disse que estava vendendo drogas, pois havia saído da prisão há pouco tempo e precisava de dinheiro. Não conhecia o réu. Informou que o

local é conhecido pelo tráfico. Aduziu que apenas o réu foi conduzido à delegacia, pois ele admitiu a propriedade das drogas, mas ninguém possuía objetos ilícitos consigo.

Wesley de Almeida Santos, ouvido em juízo, disse que nada de ilícito foi encontrado na posse do réu e das demais pessoas. Contou que visualizou uma sacola verde no interior de um buraco no local. Asseverou que havia diversas drogas no interior da sacola, que estava escondida em uma mureta, cerca de 1,5 metros de distância do acusado. Apenas o réu assumiu a propriedade das drogas, mas não se recorda a explicação sobre as drogas. Informou que não conhecia o local como ponto de venda de drogas, pois é novo no trabalho. Aduziu que os demais indivíduos não foram conduzidos à delegacia, pois ninguém carregava drogas. Não havia abordado qualquer das pessoas em data anterior.

Interrogado, o réu negou a autoria dos fatos. Asseverou que havia saído do sistema penitenciário em 28 de outubro. Disse que foi convidado a trabalhar com familiares. Afirmou que é usuário compulsivo de drogas, razão pela qual foi ao local para consumir entorpecentes. Narrou que pediu autorização dos traficantes para consumir drogas no local, mas foi obrigado a assumir a propriedade de eventuais drogas que fossem localizadas ali. Disse que todos foram abordados e assumiu a propriedade, pois tinha medo de represálias. Contou que comprou drogas e as consumiu. Estava indo embora quando foi abordado. Afirmou que possui antecedentes criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que é usuário de maconha desde a adolescência. Aduziu que possui registros por atos infracionais análogos a tráfico e furto perante a Vara da Infância e Juventude. Afirmou que as drogas estavam escondidas a menos de um metro de distância de onde estava. Disse que o responsável pela "biqueira" sempre está naquele local comercializando drogas.

Bem provadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme disposição do artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa "

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra em ao menos dois dos verbos-núcleo do tipo, notadamente guardar e ter em depósito drogas, para fins de venda, resultando configurada a tipificação do crime em comento.

A defesa busca eximir o réu da responsabilidade pelo narcotráfico sob a justificativa que não há provas suficientes do delito. Sustenta que o acusado, mero usuário, foi coagido a assumir a propriedade das drogas pelo responsável pelo tráfico na região. Entretanto, a segura e coesa narrativa fornecida pelas testemunhas é suficiente a demonstrar a real dinâmica dos fatos.

Durante o inquérito policial e em juízo, foi dito pelas testemunhas que estavam patrulhando a região dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando viram o réu conversando com outras pessoas. Aduziram que todos foram abordados, mas nada de ilícito foi localizado. Em buscas pelo local, os milicianos encontraram, a menos de dois metros de distância do réu, uma sacola verde contendo diversas drogas, a qual estava escondido em uma mureta. Questionado, o réu prontamente assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Cumprir destacar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no

depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado.

Disseram como se deu a prisão e as circunstâncias em que foram encontradas as drogas, que estavam escondidas em uma sacola próxima.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

O encontro das drogas individualmente embaladas (fls. 15/19) somado às circunstâncias do caso concreto (breve reunião com outras cinco pessoas, possíveis usuários compradores) e à segura narrativa fornecida pelos policiais não deixam dúvida acerca dos fatos e dão conta do exercício da atividade ilícita pelo réu, com a certeza necessária à sua condenação.

Conforme se verifica da folha de antecedentes criminais do réu e por ele mesmo admitido em juízo, ele fora posto em liberdade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de apelação versando também sobre condenação por tráfico de drogas. Entretanto, o acusado já estava novamente exercendo a traficância aproximadamente um mês após ser beneficiado com a liberdade.

Por outro lado, nada trouxe a Defesa para comprovar as alegações formuladas pelo acusado de que fora coagido a assumir a propriedade das drogas. De forma isolada e sem arrimo em qualquer mínimo indício de prova constante dos autos, a mera alegação de que as drogas pertenciam a terceiro estranho ao processo não presta a afastar a responsabilidade criminal do réu, especialmente diante da confissão fornecida aos policiais, pela prova testemunhal e pela robusta prova da materialidade delitiva.

O que se sabe, com certeza, é que o réu assumiu a propriedade das drogas perante os policiais e os demais indivíduos que estavam em sua companhia no palco delitivo.

Quem é apanhado, como aqui, armazenando diversas porções de variadas drogas escondidas em plena praça pública não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância, mormente considerando o histórico do réu de envolvimento com o tráfico ilícito.

Não há, assim, qualquer dúvida acerca da responsabilidade do réu pelo delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas.

Provou-se, aqui, especialmente pelos testemunhos colhidos, que o acusado exercia o narcotráfico em uma quadra pública poliesportiva, sede recreativa e esportiva,

razão pela qual far-se-ia impositivo o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06; todavia, atento ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, deixo de aplicar a majorante.

O réu era na data dos fatos imputável. Tinha plena consciência da ilicitude do ato praticado e podia determinar-se de forma diversa, preferindo, porém, o crime. Não concorrem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e aponta para o cometimento do crime pelo réu, devendo ser penalmente responsabilizado.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente

A variedade e a natureza das drogas, parte com grande poder viciante, pesam em desfavor do réu. Conforme fundamentado, as diversas drogas estavam individualmente embaladas para difusão aos usuários finais e havia porções de maconha, cocaína e crack, as últimas de efeitos profundamente deletérios à saúde dos usuários.

Na aferição dos antecedentes criminais, verifico que o réu ostenta condenações por fato praticado em momento anterior ao crime apurados nos autos, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao início do processo, o que enseja Maus Antecedentes. Assim, utilizo a condenação definitiva no processo n. 1500961-89.2019.8.26.0618 (fls. 31/35) para exasperar como antecedente criminal apto ao aumento da pena.

A personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em última ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no

momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo “A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena”, da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso

moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, “estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade” (“A mentira do réu e a Dosimetria da Pena”, artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

“...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da “não verdade”, isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

“(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras.”

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do

Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisor que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

Acerca da conduta social não há elementos que se possam valorar. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são afetos ao crime, nada havendo a valorar. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, acresço 1/3 ao patamar mínimo e fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos. Nesse passo, diminuo a reprimenda de 1/6, de forma a alcançar o total de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa.

Na terceira fase, não se vislumbram presentes causa de diminuição nem de aumento, razão pela qual fixo a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Em atenção à quantidade de pena imposta ao réu, aos maus antecedentes e à personalidade negativa, não há possibilidade de fixação de regime inicial distinto do fechado, nos termos do artigo 33, §§ 3º e 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Trata-se de condenação por tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado, cabendo ser ressaltado que por se cuidar de réu que de forma reiterada tem perpetrado o crime, impõe-se a fixação do regime mais severo.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime e os maus antecedentes do réu, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Inadmissível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso em exame, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de forma que, reputando presente a necessidade da

manutenção da custódia cautelar dos réus, nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Keven Robert Silva de Andrade à pena 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA